

1524297-94.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524297-94.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524297-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288187/2020 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 14761936 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 2200/20/301 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 2288187 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RIBEIRO GAIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MATHEUS RIBEIRO GAIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal.

Ele teria, no dia 18 de novembro de 2020, por volta de 14h00, trazido consigo, para fins de tráfico

(i) 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de maconha, acondicionados em duas porções;

(ii) 47,2g (quarenta e sete gramas e dois decigramas) de maconha, em 44 porções;

(iii) 23,9g (vinte e três gramas e nove decigramas) de cocaína, acondicionados em 31 porções;

(iv) 17,7g (dezessete gramas e sete decigramas) de crack, acondicionados em 80 porções; e (v) 4.319ml (quatro mil, trezentos e dezenove mililitros) de lançaperfume, em 51 frascos;

Tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 17/23), além da quantia de R\$ 38,00. Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, dentro de uma sacola, com o fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

Na data dos fatos, o denunciado teria trazido consigo as drogas acima descritas, dentro de uma sacola, com o fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

Policiais civis, averiguando denúncia anônima, visualizaram o denunciado em conduta suspeita, juntamente com outro indivíduo, e estes, ao perceberem a presença dos agentes no local, tentaram fugir. Todavia, o denunciado foi detido pelos policiais e, realizada sua revista pessoal, localizaram em seu poder 2 porções de maconha e a quantia de R\$ 38,00, proveniente do comércio ilícito de entorpecentes.

Além disso, em buscas pelo local, escondida atrás de entulho, localizaram uma sacola, contendo todos os demais entorpecentes acima descritos.

Questionado informalmente, o denunciado confessou que traficava drogas no local, há dois dias. Diante dos fatos, foi preso em flagrante delito. Interrogado em solo policial, MATHEUS permaneceu silente (fls. 24).

Notificado o réu (fls. 99), ele apresentou defesa prévia (fls. 102).

Inviável a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 104).

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), o boletim de ocorrência (fls. 7/10), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o laudo de constatação preliminar (fls. 17/20) e o definitivo (fls. 93/96).

Na data de hoje foram ouvidos dois policiais civis e o réu interrogado ao final.

Ouvidas as partes em alegações, a acusação pleiteou a condenação nos termos da denúncia, com a aplicação de pena mínima ao acusado. Já a defesa pleiteou, inicialmente, a desclassificação do crime para a conduta prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena mínima ao acusado, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado, artigo 33, §4º da Lei das Drogas), regime inicial menos gravoso e a conversão da pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e dos laudos de constatação provisória (fls. 17/20 e 21/23), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 93/96), com resultados positivos para COCAÍNA, TRICLOROETILENO e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, consubstanciada no relato dos dois policiais, vejamos.

O policial Júlio, reconheceu o acusado. Através de uma denúncia anônima tomou conhecimento de dois indivíduos fazendo tráfico. No local, próximo a avenida, avistou o acusado em uma esquina na companhia de um outro, local já conhecido do policial como sendo ponto de tráfico de drogas. Foi o depoente quem revistou Mateus. Com ele encontrou duas porções de maconha e 38 reais. Há uns três metros dele encontrou uma bolsinha com 40 porções de maconha, 30 de cocaína e lança perfume. A maconha encontrada na bolsinha era muito semelhante a que foi encontrada com ele. Ele confessou no local que estava fazendo tráfico porque estava

desempregado. O outro fugiu. Não o conhecia. Os fatos ocorreram na parte da tarde. A denúncia descrevia que dois indivíduos estavam fazendo tráfico no local e que estavam amedrontando a população. Na denúncia constou as características físicas e roupas dos dois. Próximo a eles não havia outras pessoas.

Policial Jacques não se recordou do acusado mas se recordou dos fatos. O local é conhecido como ponto de tráfico. Já fez várias operações. O local é conhecido com "a 10". Receberam denúncia de tráfico. Se não se engana a denúncia falava de dois rapazes, magros e de boné pelo que se recorda. Foram de viatura descaracterizada e quando chegaram eles não perceberam. Um fugiu e Matheus não conseguiu. Com ele duas "parangas" de maconha e com cerca de 30 ou 40 reais trocados. Ele disse que o entorpecente era para seu uso mas passaram a averiguar o local e encontraram próximo a ele, cerca de 5 metros, uma bolsinha com maconha, cocaína, crack e lança perfume. A maconha estava embalada da mesma forma como a maconha apreendida com ele. Não o conhecia antes. Ele acabou confessando que estava ali há dois dias.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

A relevância da palavra dos policiais se dá porque, na esmagadora das vezes, os policiais simplesmente não conseguem qualificar testemunhas que se prestem a comparecer junto a delegacia para o fim de prestar depoimento, seja em razão da Lei do Silêncio, seja porque simplesmente não querem cooperar com o Estado.

Por outro lado, não há elemento algum nos autos que demonstre que os policiais quisessem prejudicar o acusado que mal soube explicar o que estava fazendo no local dos fatos. Com efeito, alegou que já saiu de casa com o entorpecente no bolso e que pretendia comprar uma marmitta e encontrar amigos para fumar maconha na praça. Disse que havia comida em casa mas ainda assim resolveu que ia comprar a marmitta da Tia Sandra, pessoa que não foi arrolada para confirmar, ao menos, que costuma vender marmitta. Declarou que sua genitora sabia que ele usava drogas mas ainda assim lge deu o dinheiro.

A argumentação do acusado é muito frágil. Não encontra respaldo nos autos e não será aceita por este juízo, vejamos.

Matheus tem 20 anos de idade. Estava trabalhando em uma loja de tecidos no Brás mas agora está desempregado. Mora com a mãe, pai e dois irmãos. Nunca foi processado anteriormente. Não usa drogas. Na época dos fatos usava drogas. Estava com o entorpecente no bolso mas já saiu de casa com o entorpecente no bolso. Nesse dia ia ao local para pedir marmitta e encontrar com amigos. Ia usar a maconha na pracinha. Estava desempregado. No dia dos fatos a mãe não estava em casa. Os irmãos menores estavam em casa e havia comida para eles. O interrogando resolveu ir para a rua e então ia pedir uma marmitta e depois pretendia fumar maconha com os amigos. Ia comprar marmitta da Tia Sandra mas foi abordado pelos policiais. Não os viu

encontrando a droga. Não viu o entorpecente. Nunca viu os policiais antes dos fatos. Na delegacia não foi ouvido. Nunca foi processado anteriormente, nem mesmo quando aí da era adolescente. A genitora sempre soube que o interrogando usava droga. Na época ela já sabia. Foi ela quem lhe deu o dinheiro apreendido.

Já os relatos policiais são harmônicos, coerentes inclusive com o que foi dito em sede policial, fls.11/12.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova de nexos causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.87. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente

porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno MATHEUS RIBEIRO GAIA, filho de Marcos dos Santos Gaia e Liliane Ribeiro da Silva Gaia, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.13/14). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Isento de custas.

São Paulo, 28 de abril de 2022.